

1500260-98.2021.8.26.0573
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CRISTINA ESCHER
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/06/2022
... Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
2ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500260-98.2021.8.26.0573 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500260-98.2021.8.26.0573
Classe – Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241614/2021 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 52/21/219 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2241614 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELDER VANDER ROBERTO ROBSON LAURENTINO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

ELDER VANDER ROBERTO ROBSON LAURENTINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, da Lei n.º 11.343/06, e artigos 12 e 16, §2º, ambos da Lei n.º 10.826/06, porque, 1) no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 16h, na Rua Doutor José Barbosa de Barros, n.º 1690, Bloco n.º 01, apartamento n.º 101, zona rural, nesta Cidade e Comarca, transportava, guardava e tinha em depósito, para a entrega ao consumo de terceiras pessoas, 15 (quinze) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 201,62 g (duzentos e um gramas e sessenta e dois centigramas), droga esta que determina dependência física

ou psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo de constatação provisória de fls. 22/27 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 141/143, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 2) nas mesmas condições de tempo e lugar, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, marca "Taurus", do calibre 380, de uso permitido, além de 39 (trinta e nove) cartuchos intactos do mesmo calibre, da marca "CBC" (laudos periciais de fls. 130/132 e 133/136) e 3) nas mesmas condições de tempo e lugar, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) artefato de uso proibido, consistente em um silenciador (laudo pericial de fls. 133/136).

O rito da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fl. 156/157), o réu foi citado (fls. 232) e apresentou defesa preliminar (fls. 123/127). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 233/234) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

O Ministério Público, por meio de memoriais escritos, requereu a procedência da ação penal (fls. 502/507).

A defesa do réu requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e direito de apelar em liberdade (fls. 512/535).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação provisória (fls. 22/27), pelo exame químico toxicológico definitivo (fls. 141/143), pelos laudos periciais (fls. 130/132 e 133/136) e pela prova oral colhida.

A autoria está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação Alexandre Bazzo da Cunha, InvestiPol, narrou que havia denúncia anônima de que o réu estava envolvido com o tráfico de drogas, na modalidade "disque-entrega" (o usuário telefonava e o réu entregava as substâncias com seu veículo, um Onix preto). Diante disso, pediram mandado de busca, que foi concedido. Na data dos fatos, compareceu na residência do réu para cumprir tal mandado. Assim que chegou de carro no estacionamento, o réu já foi abordado. No veículo, no assoalho do carro, foram encontradas dez porções de maconha, em vários tamanhos, embaladas e prontas para a venda. No apartamento estava a esposa do acusado, que é deficiente visual. No guarda-roupas do quarto foi encontrada uma mochila com uma maleta contendo R\$ 140.000,00 em espécie, além de cinco porções de maconha, uma arma de fogo (pistola do calibre 380) carregada com carregador sobressalente, totalizando 39 munições e um silenciador para tal arma. Na ocasião, o réu admitiu que estava envolvido com o tráfico de drogas e que tinha a arma, pois estava sendo ameaçado por outro traficante que já havia roubado droga dele. Não soube explicar a origem do dinheiro, apenas informou que não confiava no banco e, por isso, guardava todo esse dinheiro em casa. Ainda, disse que receberia quarenta quilos de maconha vindo do Paraguai, levando a crer que o dinheiro seria para pagar essa droga. Também, alegou que tinha dois quilos de droga na casa de um amigo. No entanto, percebeu que era mera evasiva. Pelo que apurou, a esposa não estava envolvida. Foram feitas campanas por cerca de duas semanas, três dias na semana com vista a residência do réu, podendo constatar que ele saiu em vários momentos do dia, ausentando-se por pouco tempo, reforçando a hipótese de disque-entrega. Já participou anteriormente de ocorrências no local dos fatos. O tráfico ali normalmente é empreendido por meio da guarda das substâncias. O local não é uma biqueira, mas tem ocorrência nos apartamentos. Por fim, o réu afirmou que usava drogas.

João de Oliveira Fernandes, InvestiPol, ratificou a versão de seu colega de trabalho, acrescentando que no momento da abordagem o réu confirmou que estava envolvido com o tráfico de drogas e que era usuário de drogas.

A testemunha arrolada pela defesa Aline Zeller Pereira Souza, companheira do acusado, relatou que estava em sua casa, quando bateram na porta. Assim que abriu, deparou-se com o réu acompanhado de cinco policiais, que apontavam uma arma para a cabeça dele. Efetuaram buscas pela casa. Faziam pressão psicológica, dizendo que se levasse a mulher para cadeia, iria conhecer a regra do PCC para casos como esse. Em dado momento, levaram-no para dar uma volta para tentar localizar os dois quilos de maconha. Foi localizada a arma de fogo, que não estava montada. Encontraram a lata de biscoito onde estava guardada a maconha que o réu fazia uso. Às vezes, a declarante também consumia maconha. Havia pequenas porções de diferentes. Tinha dichavadores, seda, isqueiro e diversos petrechos para o consumo das substâncias. Não tinha ciência da arma de fogo no apartamento. Tinha R\$ 96.000,00 em casa, que estavam economizando para o casamento. Estão noivos desde 2017. Era o réu quem administrava o dinheiro físico. No dia dos fatos, o réu não tinha ido trabalhar. Durante a pandemia, o réu estava trabalhando com venda de produtos para lavador de carros. A renda mensal familiar era de cerca de quinze mil reais.

A testemunha arrolada pela defesa Maria Cristina Custódio, é vizinha do réu. Encontrava frequentemente com Elder acompanhado da esposa. Nunca ouviu dizer que Elder tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. Não conhece nenhum fato que desabone a conduta de Elder.

A testemunha arrolada pela defesa Juliana Stefani Nogueira, disse que conheceu o réu trabalhando com vendas de roupas. Posteriormente, viraram sócios de uma clínica de repouso. Mais tarde, comprou a parte de Elder na sociedade e sabe que ele iniciou trabalho como corretor de imóveis.

O acusado, Elder Vander Roberto Robson Laurentino, inquirido na esfera administrativa, afirmou que sua esposa Aline, é deficiente visual e não tinha conhecimento da traficância por ele exercida. Quanto aos demais detalhes da sua conduta, bem como procedência da droga, dinheiro e arma, deseja responder penas em juízo, após devidamente orientado pelo seu advogado, mesmo sendo cientificado que o seu silêncio poderá implicar em prejuízo na sua defesa. Em Juízo, disse que, na data dos fatos, estava chegando em casa quando foi abordado pelos policiais. Logo mandaram descer do carro e passaram a revistá-lo. Confirmou que tinha uma porção de maconha no bolso e entregou aos policiais. Os policiais lhe disseram que havia denúncia da prática de tráfico de drogas no local. Não apresentaram mandado de busca. Não encontraram nada dentro do apartamento. Pediram que entregasse dois quilos de maconha, tendo em vista que não encontraram nada no local. Levaram-no até o veículo e andaram sem destino. No caminho os policiais pediram para indicar a casa de alguém que tivesse entorpecentes, ocasião em que relatou a eles que comprava maconha para uso de um homem e que esse homem comentou que receberia quarenta quilos de maconha. Nesse momento, pararam o carro e voltaram para o apartamento. A quantidade de maconha encontrada em casa era para uso próprio. Comprava aproximadamente 50 g de maconha a cada 15 dias. A arma era de um amigo, Felipe, que estava passando por um problema pessoal e pediu para que guardasse a arma em sua casa. Aceitou guardar a arma, os cartuchos e o silenciador em sua residência como um favor. O valor encontrado estava guardando para reformar a chácara pertencente à família de sua companheira e pagar a festa de casamento. Disse que havia em casa aproximadamente R\$ 192.600,00 guardada em uma mala no guarda-roupa. Possui conta em banco, porém tem o hábito de guardar dinheiro em casa, pois não confia no banco. Aline, sua companheira, tinha conhecimento da quantia guardada. Tinha dichavador, seda, entre outras coisas que os policiais levaram, tudo utilizado para uso da maconha. A renda mensal familiar era de cerca de quinze mil reais.

A negativa do réu em juízo, destoa da versão apresentada por ele em sede policial, restando evidente que mentiu para se livrar do decreto condenatório.

De acordo com Júlio Fabrini Mirabete (Processo Penal, 4ª Edição, São Paulo, Ed. Atlas, pág. 285) “a confissão extrajudicial, que não se reveste da garantia do Juízo, é insuficiente, por si só, para embasar uma condenação, mas deve ser

admitida como prova para condenação quando amparada em outros elementos colhidos nos autos”

Assim, o art. 155 do Código de Processo Penal veda a utilização dos elementos informativos como fundamento exclusivo da decisão, mas nada impede, na atual configuração sistemática do Processo Penal, que sejam utilizados para reforçar a prova produzida em juízo, como o foram neste caso.

Neste sentido:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117192, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 16-09-2013 PUBLIC 17-09-2013).

A traficância restou comprovada pelo depoimento prestado pelos policiais que narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa a apreensão da droga descrita na denúncia.

Conforme depoimento dos policiais havia denúncia anônima de tráfico envolvendo o réu, motivo pelo qual foi autorizada a busca em sua residência, ocasião em que ele foi abordado e foram encontradas drogas no assoalho do veículo em que estava e também em sua residência.

Nessa toada, não se pode falar em contradições relevantes entre os depoimentos prestados pelos policiais que conduzam à improcedência da ação penal, sendo certo que foram uníssonos nos pontos essenciais à solução da demanda.

Nesse cenário, a versão apresentada pelos policiais é digna de toda credibilidade, já que prestaram seus depoimentos devidamente compromissados, não existindo nenhum indício de interesse em prejudicar pessoa inocente.

Ademais, pequenas imprecisões em relação a detalhes da ocorrência policial, não tem o condão de inquinar ou retirar a credibilidade do depoimento dos policiais.

De acordo com a jurisprudência:

PROVA CRIMINAL. Testemunha depoimento - Divergências apontadas pela Defesa - Ocorrência que não tem o condão de invalidar o fato principal sobre o qual ela testemunhou - Recurso não provido. As pequenas contradições da prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada (TJSP. Ap. Crim. nº 226.607-3, 4ª Câmara Crim., Rel. Des. Passos de Freitas, j. 09.12.97).

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:

08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

No tocante à finalidade com que o réu trazia e guardava a substância entorpecente, não há qualquer dúvida de que a sua intenção era a de entregá-la ao consumo de terceiros, em razão da quantidade de droga apreendida (15 porções de maconha). Além disso, os entorpecentes estavam acondicionados em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão, conforme laudo de fls. 22/27.

Com relação ao tráfico, calha ressaltar, por oportuno, que o delitos previstos nos artigos 33 e 28 da Lei nº 11.343/06 restam consumados sempre que a conduta fática do agente se ajusta com perfeição a um dos comportamentos delineados pelos dois dispositivos legais.

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - rel. ADOLPHINO RIBEIRO - RDTJRJ 20/310).

No §2º, artigo 28, da Lei de Tóxicos, está disposto que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Analisados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada destinava-se ao tráfico, mormente pela quantidade encontrada, incompatível com um mero usuário.

A condição de usuário de entorpecentes também não é suficiente para a absolvição do réu, pois isso não é incompatível com a figura do tráfico, sendo certo que várias pessoas sustentam o seu hábito com a venda de drogas.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

O mesmo destino deve possuir o veículo (Ônix), instrumento do tráfico. Saliente-se que a Constituição Federal determina a expropriação dos bens, em favor do Estado, que sejam instrumento, produto ou proveito do tráfico de drogas (art. 243, parágrafo único).

Veja-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário em que reconhecida a Repercussão Geral: "TEMA 647. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento". (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).

Em relação aos delitos de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido e posse ilegal de acessório de uso restrito, imputado ao acusado, os policiais, tanto na fase policial quanto em juízo, de forma coesa e verossímil, relataram que encontraram, na residência do réu, uma pistola, calibre 380, um carregador de arma de fogo totalmente municiado, sendo apreendido um total de 39 cápsulas de calibre 380 e um silenciador acoplável no cano da arma de fogo, artefato este de uso restrito que, segundo os laudos periciais constantes dos autos (fls. 130/132 e 133/136) encontravam-se eficazes para o disparo e possuíam potencialidade lesiva. Assim, observa-se que o réu possuía, de forma irregular, arma de fogo e munições em condição de uso e funcionamento, sendo hábil a ofender a integridade física de outrem. Agiu, pois, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ao mantê-los no interior de sua residência.

Mais a mais, não se discute, aqui, a finalidade que o acusado daria ao instrumento,

já que se trata de crime de perigo abstrato.

Com efeito, a simples posse ou guarda de armas e munições por indivíduo que não possua autorização para tanto, gera intranquilidade social, por facilitar a prática de outros graves crimes.

Neste sentido, coleciono o entendimento jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART.16 DA LEI 10.826/2003. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPLICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir se a ordem de ofício. - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, sendo, portanto, irrelevante que a munição esteja desacompanhada da respectiva arma. Habeas corpus não conhecido." (STJ HC 244.700/MG 6ª T. Rel. Min. Marilza Maynard j. 20.03.2014 DJU 10.04.2014). Mais a mais, não se discute, aqui, a finalidade que o acusado daria ao instrumento, já que se trata de crime de perigo abstrato. Com efeito, a simples posse ou guarda de armas e munições por indivíduo que não possua autorização para tanto, gera intranquilidade social, por facilitar a prática de outros graves crimes.

Ademais, afasto a causa de aumento do § 2º, do artigo 16 da Lei 10.826/03 porque se refere exclusivamente a armas e, in casu, trata-se de acessório, sob pena de indevida analogia in malam partem e consequente violação ao princípio da legalidade.

Por fim, estando o acusado, no mesmo contexto fático, a possuir arma de fogo e munições de uso permitido (sem registro) e acessório de uso restrito (silenciador), dois delitos foram praticados mediante ação única e considerando que as objetividades jurídicas dos crimes são distintas, aplica-se o concurso formal de crimes, conforme precedentes abaixo.

APELAÇÃO. Posse de munição de uso restrito e posse de munição de uso permitido. Recurso defensivo. Redução de ofício da pena-base. Ações penais em andamento não têm o condão de elevar a pena-base. Inteligência da Súmula 444 do STJ. Pleito de reconhecimento do concurso formal de delitos. Cabimento. Prática, no mesmo contexto fático, dos crimes previstos no artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/03. Fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso provido (TJSP, Apelação nº 0005648-24.2014.8.26.0663 Rel. Ministro LEME GARCIA - 16ª Câmara Criminal, julgado em 02.08.2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. I - O princípio da consunção ou absorção é verificado nas hipóteses em que a primeira infração constitui simples fase de realização da segunda, estabelecida em dispositivo diverso, em uma necessária e indistinta relação de delito-meio e delito-fim. A consunção resolve um conflito aparente de normas decorrente de uma relação de dependência entre as condutas praticadas. II - In casu, conforme consignado no decisum reprochado, muito embora haja a consumação de crimes de posse irregular de arma de fogo e porte de munição de uso permitido e de uso restrito, referidas condutas subsumem a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a

confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime meio e crime-fim. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1863921/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 DO CP; 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de aplicação, no caso concreto, da regra do concurso formal entre os delitos dos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso. 2. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, de munição, de acessório ou de explosivo, com o mesmo agente, não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 4. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 5. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. [...] O art. 16, do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos. Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos. (HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1825695/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado os delitos previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/06 e artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03. Nesses termos, ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria dos crimes descritos na denúncia, não existindo margem alguma para a absolvição.

Também não há que se falar em desclassificação para o delito de posse para uso pessoal, visto que a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o réu não condizem com o uso.

Passo à dosimetria da pena.

Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06

Em primeira fase, analisando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes (fls. 31/32) aumento a pena-base de 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Em terceira fase, deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois, muito embora o réu seja primário (fls. 31/32), o

encontro de razoável quantidade de droga (15 porções de maconha), bem como o fato de já ter sido condenado pelo artigo 28 da lei de drogas, demonstra que o réu estava a se dedicar a atividade criminosa da traficância, afastando a ideia de que ele era traficante ocasional e que incorreu no tráfico em uma única vez. Forçoso concluir-se, pois, que o acusado não se enquadra na categoria de pequeno traficante ou delinquente esporádico que a lei visa a beneficiar com a aplicação do mencionado redutor.

Com efeito, assim registrou o preclaro Desembargador Luiz Antônio Cardoso, da 3ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 0036916-89.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. 30.07.2013):

"Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Por seu turno, relatando a Apelação Criminal nº 0003671-60.2010.8.26.0073 (Comarca de Avaré, j. 25.05.2013), o eminente Desembargador Toloza Neto observou:

"Para a aplicação do referido redutor legal, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Não resta dúvida de que tal causa de diminuição de pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente punível. Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por outros crimes, não fazem jus ao benefício. A causa de redução deve ser aplicada em caráter excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo contumaz e habitual."

Artigo 12 e 16 da Lei 10.826/03

Na primeira fase da aplicação da pena do crime mais grave (artigo 16), anoto observo que o réu possui antecedentes criminais (fls. 31/32). Assim, aumento a pena-base de 1/6, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheço o concurso formal entre os crimes dos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03 (art. 70 do CP) e, diante do princípio da absorção, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 4 anos e 1 mês de reclusão e 12 dias-multa.

Por fim, considerando-se que os delitos foram praticados em concurso material, somo as penas, na forma do artigo 69 do Código Penal, as quais totalizam: 10 anos e 8 meses de reclusão e 595 dias-multa.

A pena privativa de liberdade do acusado será cumprida em regime inicialmente FECHADO, diante da quantidade de pena aplicada, além da necessidade de aplicação do regime adequado para evitar novos comportamentos análogos e visando a ressocialização do réu.

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

Diante da pena aplicada, insuscetível é a substituição por pena restritiva de direitos e também não se mostra adequado o sursis penal. Ademais, tais benefícios se concedidos ao réu não resultariam na sua ressocialização.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu ELDER VANDER ROBERTO ROBSON LAURENTINO, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 595 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 12 e 16, da Lei

n.º 10.826/03.

O réu, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderá apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do numerário apreendido em poder do réu, em favor da União, bem como veículo Ônix e dos celulares apreendidos, pois são instrumentos, produtos ou proveito dos crimes em apreço. Transitada em julgado, requirite-se a transferência.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Botucatu, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA